

数字时代人格权商业化利用的法理 重构：身份分层理论的展开

陆 青 万子怡*

内容提要：数字技术的发展正深刻重塑人格特质的呈现、传播与利用方式，致使人格权商业化利用实践呈现出高度的融合性与流动性，这对传统以“权利客体清单”为核心的人格权商业化利用理论范式构成系统性挑战。人格权商业化利用的本质，并非对个别人格要素的简单授权使用，而是对主体基于人格特质综合建构的“个人身份”所进行的符号化再生产。基于身份分层理论，数字语境中的身份呈现可以解析为三个层面：作为人格尊严之根基与自主性基础的本真身份，作为社会互动中角色扮演与公众形象建构的社会身份，以及作为可脱离物理实体并由算法与数据驱动的数字存在的虚拟身份。三者构筑了从人格内核向外围延伸的“差序格局”，各层之间存在着持续的渗透、互动与制约关系。身份分层理论并不旨在提出一种复杂概念分类标准，而意于提供一种实质的结构化的分析框架。经由对各身份层的规范检视与整合分析可知，该理论框架能够为评估人格权益受侵害程度、界定商业化利用边界提供更为精细的指引，有助于实现人格尊严保护与数字技术创新的动态平衡。

关键词：人格权 身份建构 商业化利用 个人信息保护 虚拟身份

一、问题的提出

传统民法调整平等主体之间的人身关系和财产关系，并由此形成了相对独立的人身法和财产法规范体系。然而，现实中人身关系与财产关系之间并不存在一道清晰的界限，尤其在婚姻家庭领域，二者的交织尤为明显，相关研究亦较为丰富。相比之

* 陆青，浙江大学光华法学院教授；万子怡，浙江大学光华法学院民商法学博士研究生。

本文系国家社科基金一般项目“数字身份的法律保障机制研究”（23BFX027）和浙江省哲学社会科学规划领军人才培养课题“数字经济发展与民法制度保障”（25QNYC006ZD*）的阶段性成果。

下，人格与财产之间的内在联系及其法律调整机制在学理上的探讨较为薄弱，也更为谨慎。一方面，将人格与财产过度绑定，容易引发人被“物化”的质疑；另一方面，受制于历史路径依赖，传统人格权法的探讨更侧重于对人格利益的消极保护而非积极利用。^{〔1〕}我国民法典第989条明确将人格权编的立法目的限定于“调整因人格权的享有和保护产生的民事关系”，即反映出这一立场。

然而，理论研究的生命力在于回应实践的真问题。在数字技术的强力驱动下，人格权商业化利用实践正以前所未有的速度蓬勃发展。商业化利用的对象已从传统的姓名、肖像、声音，扩展至个人的生物特征、行为数据、虚拟形象、情感与心理特征；利用方式也突破了简单的授权使用，发展出直播带货中的形象植入、数字人主播、“AI陪护”、“数字复活”等复杂形态。这些人格权商业化利用的创新实践不仅挑战了传统人格权理论的解释限度，也暴露出既有法律规制在权利配置、合作机制、责任认定、法律救济等方面的系统性不足。

有鉴于此，本文将在梳理人格权商业化利用的既有学理的基础上，引入身份分层理论，试图弥合理论发展与商业实践之间的鸿沟，重构数字时代人格权商业化利用的法理基础。本文旨在说明，人格权商业化利用的本质，并非对个别人格要素的简单授权使用，而是对主体基于人格特质综合建构的“个人身份”所进行的符号化再生产。因此，法律规制应当实现从保护抽象的“人格统一体”到进行具体、精细的身份治理的范式转换，以应对数字时代人格权商业化利用的规范需求。需要说明的是，本文使用的“身份”或“个人身份”概念，主要在个体身份识别与身份认同的意义上理解，意指个体在社会交往与自我认知中形成的、具有辨识度与自我定位意义的人格形象，因此区别于传统民法在人身关系范畴下与“人格”相并列的“身份”，后者主要针对婚姻家庭法上的特定地位与关系。^{〔2〕}

二、人格权商业化利用的既有理论审视

在展开深入讨论前，有必要对“人格权商业化利用”这一概念本身进行界定和澄清。在笔者看来，“人格权商业化利用”^{〔3〕}显然不是一个严格意义上的规范用语，其仅具有描述性的意义。相近的表述还有“人格权商品化”、^{〔4〕}“人格商业化利

〔1〕 See Giorgio Resta, *The New Frontiers of Personality Rights and the Problem of Commodification: European and Comparative Perspectives*, 26 *Tulane European and Civil Law Forum* 33, 33-65 (2011).

〔2〕 关于本文使用的“身份”或“个人身份”概念，除后文第三部分有进一步阐释外，还可参见陆青：《数字时代的身份构建及其法律保障：以个人信息保护为中心的思考》，《法学研究》2021年第5期，第8页以下。

〔3〕 使用“人格权商业化利用”这一表述的，参见姚辉：《关于人格权商业化利用的若干问题》，《法学论坛》2011年第6期，第10页（该文亦使用“人格利益商业化利用”的表述）；程啸：《论人格权的商业化利用》，《中国法律评论》2023年第1期，第42页；王泽鉴：《人格权法：法释义学、比较法、案例研究》，北京大学出版社2013年版，第254页（该书先后使用了“人格权的商业化”和“人格商业化”两种表述，未作严格区分）。

〔4〕 参见王利明：《论人格权商品化》，《法律科学》2013年第4期，第54页。

用”、〔5〕“人格权益商业化利用”、〔6〕“人格要素商业化利用”〔7〕等。本文采用“人格权商业化利用”的表述方式，主要基于两点考虑：其一，“商品化”的表述容易引发将人格降格为商品的伦理质疑，造成不必要的概念争议；其二，无论是描述为人格、人格权益还是人格要素的商业化利用，其法律基础最终都需要回归到人格权的权利构造中来理解。此外，本文对“人格权商业化利用”采广义理解，不仅包括权利主体对人格权的主动利用，还包括人格权的被动商业化利用情形。盖所谓“商业化”，本质上是人格要素的价值变现过程，与行为人的主观状态并无必然关联。实践中，这两种利用方式也可能发生转化，具有一并讨论的必要性。

以此为背景进行审视，可以发现，关于人格权商业化利用的学理基础，依然缺乏定论。对此主要存在三种观点：一是否定人格权可以商业化利用（否定论）；二是仅承认部分人格权（主要与人格标识相关）可以商业化利用（区分类型论）；三是在更广泛意义上承认人格权可以商业化利用，但也强调要予以必要限制（广泛承认论）。这三种理论均有可商榷之处，细述如下：

（一）否定论的观点及其批判

明确反对人格权商业化利用的学者不多，但也有例外。比如，有学者明确指出，“不具有专属性特征的姓名权和肖像权，以及不具有固有性特征的法人人格权，虽为民事权利但非人格权”。在其看来，“提出人格权的商业化这个命题本身就违反人格权的专属性特征，不符合人格权的民法表达的基本要义”。〔8〕还有学者通过对“标表型人格权”（指权利人基于独特标记、符号、声音等享有的权利）的分析，提出人格标识的商业化需依托独立于标表型人格权之外、实为特殊财产权的“人格标识使用权”。按照这一理论，标表型人格权需进行“纯化”处理：将人格标识的使用权能从原有权能中剥离，仅保留决定、变更人格标识的内在属性，由此形成双重独立的权利结构，即区分为禁止商业化的标表型人格权与允许商业化的人格标识使用权。〔9〕后一种观点与美国法上将人格权商业化利用纳入公开权的调整范畴的规范思路其实颇为接近。在美国法上，公开权具有鲜明的财产权属性，是从隐私权中剥离出来的个人形象特征的商业利用权能。美国法围绕公开权构建起以经济利益保护为核心的财产权机制。〔10〕

上述两种观点，究其本质，在于强调人格权的专属性，并认为专属性与商业化利用存在不可调和的矛盾。但事实上，人格权的专属性是特定历史语境下多重观念交融

〔5〕 参见刘召成：《人格商业化利用权的教义学构造》，《清华法学》2014年第3期，第118页。

〔6〕 参见王叶刚：《论可商业化利用的人格权益的范围》，《暨南学报（哲学社会科学版）》2016年第11期，第115页。

〔7〕 参见程啸：《我国民法典对人格要素商业化利用的规范》，《人民法院报》2020年12月17日第A5版。

〔8〕 邹海林：《再论人格权的民法表达》，《比较法研究》2016年第4期，第1页，第14页。

〔9〕 参见房绍坤、曹相见：《标表型人格权的构造与人格权商品化批判》，《中国社会科学》2018年第7期，第144页以下。

〔10〕 “公开权在于保护个人的特征（identity），以认同其人，作商业上使用而具财产价值。”前引〔3〕，王泽鉴书，第264页。

的产物。一方面，近代自然法学派的天赋人权理论和德国古典哲学中“人是目的，不是工具”的道德律令，深刻影响了对人格权的根基性认识。人格权被阐释为人类作为理性存在物所固有的权利，并逐渐形成了“人格权不可交易”的法律共识。另一方面，早期人格权法将人格权局限于防止侵害的消极功能，客观上强化了人格权的专属性特征。^{〔11〕}本文无意对这一传统学说的正当性提出质疑，但在笔者看来，坚持人格权的专属性与人格权的商业化利用之间并不存在根本法理冲突：第一，人格权之专属性旨在保障主体与其内在人格利益的不可分离性，防止人格的客体化；而人格权的商业化利用并非人格权本身的转让、放弃或继承。它既不导致权利主体资格的变更，亦不意味着人格与权利人的固有联系被切断。第二，坚持人格权专属性的核心在于保障人格自由和人的尊严，这并不必然否定人格权的商业化利用，毋宁是要为之提供合理的制度安排。第三，前述两种见解均形成于民法典颁布之前，而民法典不仅将人格权独立成编，在第993条确立了人格标识等的许可使用制度，在第1021—1023条构建了完整的肖像权使用规则体系，还在侵权责任编第1182条专门规定了侵害他人人身权益造成财产损失时的赔偿计算标准，显然并未采取类似美国公开权那样将财产利益从人格权中剥离出来的规范路径。因此，在民法典颁行之后，前述两种见解对我国法的应用价值有限。

（二）区分类型论的观点及其批判

也有一些学者尝试对人格权进行类型化区分，主张仅姓名权、肖像权等标表型人格权可在许可使用范畴内有限商业化利用。^{〔12〕}还有类似观点试图区分“专属性人格权”与“财产性人格权”，认为仅后者具备商业化利用可能。^{〔13〕}另有学说倾向于以“物质性人格权”与“非物质性人格权（精神性人格权）”为界，^{〔14〕}将可商业化利用的人格权限定于后者。^{〔15〕}

在笔者看来，上述类型化路径均存在一定的局限。第一，尽管民法典第993条仅明确列举姓名、肖像等可作为许可使用对象，但该条以“依照法律规定或者根据其性质不得许可的除外”作为但书，其规范结构实为“原则允许、例外禁止”，并未将商业化利用严格限定于标表型人格权。第二，所谓“专属性”与“财产性”人格权，

〔11〕 参见王利明：《人格权的属性：从消极防御到积极利用》，《中外法学》2018年第4期，第850页以下；前引〔3〕，姚辉文，第11页。

〔12〕 参见温世扬：《中国民法上的“公开权”——〈民法典〉人格标识许可使用规定之解析》，《当代法学》2021年第2期，第18页。

〔13〕 参见黎桦：《专属性人格权与财产性人格权分离论——基于人格权商品化研究之检讨》，《湖北社会科学》2015年第10期，第151页。

〔14〕 关于精神性和物质性人格权的分类，参见张俊浩主编：《民法学原理（重新校订版）》，中国民主法制出版社2024年版，第128页，第131页以下；王利明：《人格权法的新发展与我国民法典人格权编的完善》，《浙江工商大学学报》2019年第6期，第16页。

〔15〕 该观点认为，物质性人格权是自然人对物质性要素的不可转让的支配权，“与精神性人格权存在于无形的精神价值之中不同，物质性人格权存在于生命有机体之中，其难以与主体相分离，客观上难以成为商业利用的对象”。前引〔6〕，王叶刚文，第120页。

在界定标准上往往陷入循环论证，实为对商业化利用可能性的同义反复，并未提供实质性的分类指引。第三，物质性与非物质性人格权的二分法虽意图强调对与人格尊严紧密相关的物质性人格权予以更强保护，但其区分标准同样值得商榷。盖所有人格权皆与人格尊严相关，此种区分最多仅说明物质性人格权与尊严的关联或许更为直接和紧密，却难以绝对化。最后，也是笔者最想强调的，以人格权类型化为基础的“可商业化利用清单”思维，已无法有效应对数字环境下人格权商业化利用所呈现出的流动性、场景性等特征。数字技术的发展已从根本上模糊了各类人格要素的传统界限，并催生出大量跨类型、复合型的商业形态，同一人格要素在不同场景中可能呈现出完全不同的属性与价值。例如，歌手独特的音质既可视作与身体相关的特征，当其被用于 AI 语音合成创作歌曲时，又体现了声音标识的财产价值。若被用于克隆数字人或录制侵权言论，则可能同时涉及名誉保护乃至人格尊严的复杂问题。人格要素能否以及如何商业化利用，其价值与风险并非由其所属的抽象权利类型决定，而是更取决于其在具体应用场景中扮演的角色和承载的功能。

（三）广泛承认论的观点及其批判

另有一些学者在更广泛意义上认可人格权的商业化利用。例如，有学者认为，除生命、健康、自由等核心权利外，其他人格权原则上都可以商业化利用。^{〔16〕}有认为凡具有可利用价值的人格权即具备商业化利用潜能，甚至物质性人格权也有一定的积极利用面向。^{〔17〕}有学者认为，人格的商业化利用在形式上近乎覆盖了人格利益的所有方面，因此不可能完成对其对象的穷尽、封闭式界定。^{〔18〕}在描述人格权为何可以商业化利用时，也存在多种解释路径：或强调人格权的权能中内在地包含着经济性利益；^{〔19〕}或主张部分人格权权能具有与人身的可分离性；^{〔20〕}或指出人格要素本身即承载着经济利益。^{〔21〕}

与试图通过明确人格权类型以确定其商业化利用可能性的规范思路不同，“广泛承认论”顺应了人格要素财产价值日益凸显的现实趋势。然而，在应对数字时代人格权商业化利用所呈现的新问题时，该理论同样存在局限性。其在方法论上仍未能完全摆脱“权利客体清单”的思维定式，只不过将清单范围从姓名、肖像等有限人格标识，扩展至更广泛的“具有经济利用价值”的权益。此种思路在面临数字时代人格要素利用的高度融合性与流动性时，将与“区分类型论”一样捉襟见肘。例如，虚拟主播的商业价值往往难以被简单归入某一既有人格权项下，而是来自于其基于声音、形象、表演风格、互动内容乃至算法推送之共同作用而形成的复合型身份。可见，“广泛承认论”缺乏有效的分析工具来建构其内在层次以满足相应的规制需求。

〔16〕 参见前引〔3〕，姚辉文，第10页。

〔17〕 参见前引〔4〕，王利明文，第57页；前引〔11〕，王利明文，第851页。

〔18〕 参见前引〔5〕，刘召成文，第129页。

〔19〕 参见前引〔3〕，姚辉文，第11页。

〔20〕 参见前引〔4〕，王利明文，第55页。

〔21〕 参见前引〔3〕，程啸文，第49页。

三、身份分层理论及其具体展开

前文分析表明，无论是试图通过类型化明确边界的“区分类型论”，还是扩大清单范围的“广泛承认论”，在面对数字时代人格要素利用日益呈现的融合性、流动性特征时，均显露出“权利客体清单”思维的固有局限，无法有效应对基于复杂身份叙事的人格权商业化实践产生的规范需求。为化解这一困境，本文试图从静态的“人格要素”转向动态的“身份建构”，通过引入身份及其分层理论，分析人格权商业化实践中人格特质、社会互动与经济逻辑多元交织的内在机理，从而为构建一种兼具解释力、适应性与精细度的规范框架奠定理论基础。

（一）身份理论的引入

正如本文开篇所言，笔者所探讨的“身份”，是指个体在社会交往与自我认知中形成的、具有辨识度与自我定位意义的人格形象。这一“身份”概念，对应于英文中的“identity”一词，意在强调个体在特定语境中的主体性、同一性与差异性。于个人而言，身份是使其与他人相区别并借以归属于特定群体的人格特质集合，其形成本质上是自我认同与社会认同在互动中交织的动态过程。这一身份观念的形成和发展，在社会学、心理学、哲学等领域已有诸多研究，^{〔22〕}只不过受制于传统民法对“身份”概念的狭义理解，我国法学界对“identity”所指向的社会性、建构性身份及其法律意义的关注尚较有限。

在身份建构的视域下，人格权商业化利用可被解读为个体将身份认同予以货币化的社会实践。借用美国社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧论”，日常生活中的自我呈现本质上是生活舞台上的角色扮演与印象管理。^{〔23〕}商业化语境则赋予这一过程以经济理性，将其与资源投入及收益回报紧密绑定。例如，艺人通过社交媒体经营“励志人设”，不仅投入时间，更通过情感劳动将私人经验转化为可交易的符号资本。身份建构始终嵌入社会关系之中，既包含个体的主动呈现，也深受特定社会场域的结构性的规训（如平台算法、商业合同条款的影响）。商业化利用正是这种双重维度交汇的枢纽：它既是个体积累社会资本的途径，也是各种社会力量形塑个体身份的载体。^{〔24〕}

从身份建构的角度解读人格权的商业化利用，可以更好地说明商业实践的动态过程。网红通过直播塑造个人形象获得商业收益，不仅仅是对其姓名、肖像等人格标识的简单的对价交易，更是其整个身份叙事的商业化再造。这也解释了为何传统理论难以回应同一人格要素在不同语境中价值悬殊的困境。比如，健身博主的身材之所以能

〔22〕 相关梳理和介绍，参见前引〔2〕，陆青文，第11页以下。

〔23〕 参见〔美〕欧文·戈夫曼：《日常生活中的自我呈现》，冯钢译，北京大学出版社2008年版，第212页以下。

〔24〕 数字时代的个体通过商业化策略积累社会资本，需同时受平台商业规则和受众期待的制约。See Susie Khamis, Lawrence Ang and Raymond Welling, *Self-branding, “Micro-celebrity” and the Rise of Social Media Influencers*, 8 (2) *Celebrity Studies* 1, 12-14 (2016).

“变现”，关键在于其已融入一个被受众识别、认可并追随的身份叙事之中，而普通人的同类特征则缺乏类似叙事的嵌入与支撑。

（二）身份分层理论的确立和展开

身份理论揭示了人格权商业化利用是一个动态的身份建构过程。为进一步理解并对其进行有效引导和规范，还须对身份作进一步的结构化阐释，以提供更为精准的分析框架。

对此，法学界已有一些颇具启发性的观点。例如，有学者提出“星云”理论来理解人的身份建构中自我与人格要素、身体组织等的关系，即将自我视为引力核心，身体器官、组织乃至体外装置如同星云中的天体，依其与自我意识的融合程度，动态分布于不同轨道。越靠近外围，物的属性越强，与自我的分离越清晰；越接近内核，则越被自我认同渗透，最终与人格核心融为一体。依其理论，假肢应视为人体的组成部分还是仅作为外在工具，取决于其被使用者感知为“自我延伸”的程度。^{〔25〕}还有学者聚焦于人格权的可转让性问题，支持“核心—外围秩序”理论。该理论将生命权、健康权、身体权等作为核心人格秩序，将其他权利作为外围的生活利益秩序。这一见解与“星云”模型有异曲同工之妙，均强调人格要素的可分层性与动态特征。该学者还就此将人格权区分为五种类型，依据其与人格核心的密切程度判断相关权利的可转让性。^{〔26〕}然而，“星云”理论虽极具解释力，但其描述性大于规范性，因过于抽象而缺乏具有可操作性的裁判指引。“核心—外围秩序”理论虽构建了相对清晰的类型化框架，却由于分类相对固化，难以充分回应现实中多元利益交织、新型人格形态不断涌现带来的规范张力，解释力仍显不足。

在反思上述理论的基础上，笔者尝试提出一种结构化的身份分层框架，将人格在商业化语境中的呈现划分为三个层次：本真身份、社会身份与虚拟身份。该框架并不意图覆盖身份的所有哲学或社会维度，而是聚焦于法益识别与规制需求，旨在为人格权商业化利用的法律规范提供更具包容性的解释方案。

“星云”理论和“核心—外围秩序”理论都主张在身份建构中存在着一个自我的内核层，即“我之为我”的主体性根本。对此内核，笔者倾向于采用“本真身份”加以概括。使用“本真”一词，主要是受海德格尔存在论中“本真性”（authenticity）的哲学思考的启发，同时也吸收了戈夫曼拟剧论中关于社会表演与自我呈现的洞见。具体来说，在海德格尔看来，人的存在可以分为两种基本状态，一种是沉沦于日常闲谈、迷失于“常人”之中的非本真存在；另一种是“本真的亦即本已掌握的自己”，即能够直面自身可能性、承担起自由与死亡责任的本真存在。^{〔27〕}

〔25〕 Cfr. Gaetano Anzani, *Identità personale e “atti di disposizione della persona”*, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, Vol.7-8, II, 2008, pp.216-218.

〔26〕 具体分为物理性人格权、标表型人格权、外界评价类人格权、私人空间类人格权和其他人格权益五种类型，依次建构从核心到外围的规范秩序。参见张挺：《一身专属性视角下人格权的可转让性及其界限》，《法学》2025年第5期，第125页以下。

〔27〕 参见〔德〕海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映、王庆节译，商务印书馆2018年版，第166页以下。

海德格尔倡导的“诗意的栖居”，其核心内涵是指人能从“充满劳绩”的生存状态中挣脱出来，在“大地”与“天空”之间本真地测度自身。^{〔28〕}换言之，“以自我内心的规定性和创造力来抵制现代科技消抹一切个性界限的危险，将现实人生诗意化”。^{〔29〕}戈夫曼的拟剧论则从微观社会互动层面提供了另一重要视角，他将社会生活中的自我呈现类比为戏剧表演，提出了“前台”与“后台”的区分。个体在“前台”运用“印象管理”策略，扮演特定角色以符合社会期待；而“后台”则是个体暂时卸下角色面具、流露并安顿真实自我的相对私密空间。^{〔30〕}海德格尔的哲学沉思与戈夫曼的社会学分析，虽然源于不同理论传统，但均揭示了一个关键事实：在社会规训的“前台”表演与“常人”的沉沦状态之下，存在一个进行着自我抉择并需要在“后台”予以守护的、不可让渡的“真实自我”。这一发现打破了关于身份统一完整的静态假设，将自我置于“关系建构”的动态视域中加以考察。

基于上述理论，笔者从身份建构的规范视角，尝试界定两种不同层面的身份，即本真身份和社会身份。本真身份是指人在追求真实自我或者说本真状态的内心体验过程中所形成的身份认同，具体表现为作为独一无二个体的核心生物特征与深层心灵特征（如内在价值观、情感模式、精神追求）的总和。它源于个体对“我是谁”的内在感知与确认，具有相对的稳定性和内在性。社会身份，则是指个体在具体社会关系网络中，为寻求外部认同、扮演社会角色或实现交往目的，通过有意识或无意识的“表演”与互动而建构起来的角色形象与公共人格。其外在表征具有多样性，既包括姓名、肖像、声音、特定形象等具有直接公共识别度的符号，也涵盖个体在长期社会活动中积累的职业声誉、专业信用、社会影响力等。值得注意的是，这种身份具有情境性和多元性，个体在不同社会场域中可能呈现不同的角色身份，且社会和他人的行为存在特定的角色期待。无论是向内探索的本真身份，还是向外建构的社会身份，都反映了个体在不同维度上的生存状态。

然而，立足于现实社会语境的本真身份与社会身份的二元框架，在解释数字时代的人格呈现方式时依然存在不足。数字空间绝非现实的简单镜像，而是已演变为一个拥有内生规则与独特机制的自主领域。在此背景下，个体的身份建构呈现出前所未有的离散性、可塑性乃至可技术性。早在20世纪90年代，美国学者雪莉·特克尔便洞察到，在虚拟空间中个体得以超越物理躯体的束缚，在不同社群中并行不悖地塑造多元身份。^{〔31〕}当下人工智能技术尤其是深度合成技术的迅猛发展，更是将这种身份的流动性、可操纵性推向了极致，使得身份与生物基础之间的必然联系进一步松绑，甚

〔28〕 参见〔德〕海德格尔：《演讲与论文集》，孙周兴译，商务印书馆2018年版，第209页以下。

〔29〕 赵静蓉：《诗意栖居的本真性——论海德格尔在现代性进程中的“返乡之途”》，《南京师大学报（社会科学版）》2005年第1期，第115页。

〔30〕 关于“前台”“后台”、区域与区域行为、印象管理艺术等概念的充分阐释，分别参见前引〔23〕，戈夫曼书，第19页以下，第93页以下，第179页以下。

〔31〕 See Sherry Turkle, *Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet*, Simon & Schuster Press, 1995, pp.12-13, pp.177-180.

至催生了脱离特定人物理参与的“合成身份”。因此，有必要将“虚拟身份”确立为一个关键的分析层次，并将其界定为在数字技术架构中主动创建或被动生成、具有可识别性与交互性的数字化身。它不仅是对本真身份与社会身份的映射与简单重构，更在虚拟空间的复杂交互中演化为一个承载着独特社会关系与财产价值的独立存在。

于此，本真身份、社会身份和虚拟身份的三层结构得以基本确立，为后续分析和检视相关法律问题奠定了基础。

四、身份分层理论的规范检视

任何理论的生命力，最终取决于其解释和应对现实问题的能力。为避免陷入纯粹的逻辑推演，笔者将运用身份分层理论对现行法进行系统检视，以期揭示现行法在应对数字时代人格权商业化利用挑战时的规范不足，并为构建科学、合理的规制体系提供理论支撑。

（一）本真身份层的规范检视

在数字技术深度重塑人格边界的当下，引入“本真身份”这一概念的根本价值，在于为人格权商业化利用的规制构建一个超越简单要素归类、更具层次性与动态适应性的分析框架。所谓“本真”，并非将人固化于某种预设的“原初状态”，而是强调在技术环境中，个体仍应保有自主探索、定义并实现“我之为我”的自由与可能性。

传统规制模式倾向于采取“非此即彼”的二元判断，将人格要素简单归类为“可商业化”或“不可商业化”的范畴。然而，数字技术的发展使此种简单归类难以应对现实挑战。脑机接口、神经数据分析等技术首次使对人格根基的“侵入”与“度量”成为可能，个体的神经活动与思维轨迹能够被直接读取、解析甚至干预。^{〔32〕}情感计算则可将内在情感反应量化为可交易的数据标的。^{〔33〕}甚至个体的知识状态、认知能力、认知判断过程也能成为机器学习和挖掘的对象。^{〔34〕}此类技术若得合理利用，可在医疗康复、教育创新等领域发挥积极作用，如通过脑机接口帮助瘫痪患者恢复运动功能，或借助情感计算优化人机交互体验，或利用教学智能体模拟教师的认知判断能力，当然也有一定的商业化空间。然而，若使用不当，在商业资本的助推下，其风险将远超传统意义上的隐私泄露。这种对人格内在维度的商业化开发，不仅可能侵蚀个体的心智自主性，甚至可能从根本上动摇“人”作为目的自身的主体性地位，使人面临被彻底工具化的风险。

〔32〕 相关技术的最新发展及其对人格权保护的影响，参见吴旭阳：《脑机接口新发展背景下法律权利体系探析》，《政法论坛》2025年第2期；张红：《脑机接口技术发展中的的人格权益保护》，《中国法学》2025年第2期。

〔33〕 参见褚婧一：《情感计算的信息隐私法律风险及其应对》，《交大法学》2023年第3期，第66页以下；王禄生：《情感计算的应用困境及其法律规制》，《东方法学》2021年第4期，第54页以下。

〔34〕 机器学习不仅能预测结果，还能学会人类复杂的、非理性的决策过程。See Joshua C. Peterson *et al.*, *Using Large-scale Experiments and Machine Learning to Discover Theories of Human Decision-making*, 372 Science 1209, 1209–1214 (2021).

本真身份理论的首要关切，在于将人格权的保护范围从物质性层面拓展至精神完整性的维度。现行法律体系主要侧重于生命、身体、健康等物质性人格层面的保护，而前述数字技术的深入发展已让人深刻意识到，人格的完整性还需涵盖精神层面的统一性与自主性。事实上，学界对此已有深入探讨，例如面对脑机接口等新技术，主张通过拓展解释既有具体人格权与一般人格权来回应；^{〔35〕}亦有观点提出创设“精神完整权”^{〔36〕}或“神经权利”^{〔37〕}等新兴权利。这些探索虽具启发性，但其思路仍未完全摆脱“权利客体清单”的枚举式观察。从身份建构的动态性角度来看，不仅需要注意到“精神完整性”这一核心议题，而且需要将对本真身份的法律保护从对“某项既定权利是否被侵害”的静态审查，转向对“特定技术应用在具体场景中是否对人格的完整性根基造成了不可逆的侵蚀”这一动态风险的持续性评估。

在明确保护范围的基础上，本真身份的规制逻辑旨在实现从“绝对禁止”到“严格限制下的许可”的梯度框架建构。本真身份因触及人的主体性根本，原则上禁止商业化是其法律底线。但人对本真自我的探求，依然有一定的自由决定空间，只不过对这种自由需要保持警觉，相关决定应符合伦理要求。因此，对本真身份的保护并非意味着全面禁止任何商业化利用，而是要求立法者根据行为对人格根基的干预深度，构建一个梯度化的规制框架。^{〔38〕}我国民法典人格权编已展现出初步的分级规制智慧：一方面，严格禁止人体细胞、组织、器官的买卖（第1007条）；另一方面，在器官捐献（第1006条）和临床试验（第1008条）等场景中，在尊重主体自决的前提下，辅与伦理审查等程序保障。此种差异化的规范思路，也为应对新型数字技术对本真身份的深层介入提供了重要参照。值得注意的是，国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会于2023年12月发布的《脑机接口研究伦理指引》亦体现了分类治理的规制逻辑。该指引针对修复型与增强型等不同研究类型，设置了差异化的伦理要求。其第4.2条（社会与科学价值）指出，脑机接口研究应主要致力于修复型脑机接口技术以服务公众健康，对非医学目的的增强型技术（如注意力、睡眠和记忆调节等），则应在严格规范、明确获益的前提下审慎探索。^{〔39〕}这种基于类型与风险的区分治理模式，在坚守人格尊严底线的同时，为负责任的科技创新保留了必要空间，颇值赞赏。

为实现对本真身份的有效保护，还有必要推动规制模式由静态防御向动态治理演

〔35〕 参见前引〔32〕，张红文，第107页以下。

〔36〕 参见李筱永：《脑机接口技术背景下精神完整权的逻辑证成和制度构想》，《政法论丛》2024年第3期，第52页以下。

〔37〕 参见童云峰：《脑机接口技术应用背景下神经权利的证立与穿透式保护》，《暨南学报（哲学社会科学版）》2024年第8期，第70页以下。

〔38〕 有观点指出，即使在物质性人格权的规范语境下，人格要素的积极利用甚至一定程度的商业化依然有其空间。但这种利用必须遵循“伦理优先、兼顾效益”的基本原则，并接受严格的法律规制与伦理审查。参见孟勤国、牛彬彬：《论物质性人格权的性质与立法原则》，《法学家》2020年第5期，第10页。

〔39〕 参见科学技术部官网，<https://www.most.gov.cn/kjbgz/202402/P020250729548085721952.pdf>，2025年12月14日最后访问。

进。我国个人信息保护法已经实现了从保护“作为结果的个人信息”到规制“作为生成过程的个人信息”的范式转变，通过敏感个人信息保护、同意规则等体现对身份建构过程的关注。^{〔40〕}然而，面对数字技术带来的情感计算等新型风险，其规制效能仍显不足。对此，欧盟《人工智能法》基于风险等级梯度规制人工智能技术应用的思路具有借鉴意义。尤其是，其对“禁止的人工智能实践”从利用对象、目的、方式及可能带来的影响等方面展开详细的类型化规范，不仅体现了对人格根基的前置性保护，还通过确立清晰、可预期的负面清单，为技术创新划定了必要的伦理与法律边界。^{〔41〕}虽有观点认为人工智能统一立法为时尚早，^{〔42〕}但从本真身份的保护维度审视，针对那些深度介入情感、思维等深层人格活动的数字技术，构建全流程的行为监管与强化伦理审查机制已刻不容缓。这并非要扼杀创新，而是通过设定必要“护栏”，确保创新不偏离保障人格尊严的根本方向，为人的“诗意栖居”提供可能。

（二）社会身份层的规范检视

与作为人格根基、原则上禁止或严格限制商业化的本真身份不同，社会身份天然具有外部性与交互性。它不仅是个体自我呈现的载体，更成为一种可以在社会互动中不断形塑的符号资源。

在社会身份面向，传统的人格权商业化利用实践多采用姓名、肖像等许可使用相同的模式，学理对此颇多研究，此处不赘。值得注意的是，随着数字技术的深入发展，社会身份的商业化形态从对主体（尤其是名人）既有社会影响力的单向利用，逐渐演变为个体在多元平台上持续进行“前台表演”并主动或被动参与身份塑造的复合过程。^{〔43〕}这一过程不仅体现为个体的自我呈现，更受到算法逻辑、资本介入与公众期待的共同塑造。借助戈夫曼的拟剧论视角，^{〔44〕}社交媒体、直播平台等数字化“前台”拓展了身份表演的场域，个体可通过内容创作与人设管理等方式建构社会身份。资本合作方作为“制片人”对表演行为实施深度干预，平台算法作为“隐形编剧”，借由流量分配机制设定特定内容形态偏好，二者共同规训着身份表演的“剧本”。与此同时，消费者作为参与性的“共构者”，通过点击、点赞、分享与消费等行为，不仅完成交易活动，也在购买与特定艺人相关的商品或服务时同步完成了对自

〔40〕 参见前引〔2〕，陆青文，第14页以下。

〔41〕 欧盟《人工智能法》中关于禁止的人工智能实践的具体条文表述，参见朱悦：《欧盟〈人工智能法〉研究：以立法过程为视角》，上海人民出版社2025年版，第119页以下。

〔42〕 参见王凌峰：《未来尚未到来——人工智能统一立法模式的内在悖论》，《交大法学》2025年第6期，第47页以下。该文主张现有法律框架足以评价和有效控制人工智能的应用及其直接后果，无须额外的统一立法。

〔43〕 或有质疑认为此类社交媒体、直播平台交易已经超出了人格权商业化利用的讨论范畴，但正如笔者在前文所述，“人格权商业化利用”只是一个描述性概念，而非规范用语。将此类涉及人格要素综合利用的商事活动纳入人格权商业化利用的规范语境，不仅具有理论可行性，在保障个体人格发展免受商业资本不当侵蚀上亦具有重要意义。

〔44〕 个体的自我呈现不仅依赖于自身的“表演”，更依赖于其所在“剧班”的协同合作。关于“剧班”理论，参见前引〔23〕，戈夫曼书，第150页以下。

身特定文化身份的认同建构。〔45〕在这一由表演者、资方、算法与公众共同参与的商业化复杂图景中，法律规制须针对不同参与主体的利益诉求，提供差异化的权利配置与救济路径。

其中，最值得关注的是主播、艺人等与资方的合作关系，核心议题在于如何平衡商业化过程中前者对其社会身份的自主控制权与后者对其投资预期稳定的合理需求。对主播、艺人而言，其核心利益不仅体现在对个人形象与创作方向的主导，也涉及对身份衍生财产价值的合理分享；而资方则需应对因主播、艺人违约跳槽、“人设崩塌”等引发的诸多商业风险。实践中，资方常通过设置高额违约金、〔46〕单方解约权、〔47〕账号归属约定、〔48〕“道德条款”〔49〕等规避这些风险。但这些约定常以格式条款的方式作出，其效力常引发争议。对格式条款公平性的评判，本质上需以法律上清晰的权利义务配置为基础，相关争议频发也说明了传统偏重事后救济的人格权保护模式在应对动态化、持续性的商业合作关系时存在局限性。

从社会身份建构理论出发，网络主播、艺人与资方之间法律关系的界定，关键在于厘清社会身份的形成逻辑，并评估主播、艺人之“自我身份特质”在其中所占的权重。主播、艺人的社会身份本质上是其“前台表演”与“自我身份特质”相互融合的产物。其中，前者受到资本规划、平台算法及公众期待等外部因素的系统性塑造；而后者源于主播、艺人通过独特才艺、稳定表达风格与个人魅力等内在特质所建构、并被公众深度认同的身份内容，体现其在社会互动中的自主性与创造性。因此，法律对相关权益进行配置时，应基于各方在身份价值创造过程中的实质性投入与贡献

〔45〕 关于消费文化对消费者身份塑造的影响，参见 Joseph E. Davis, *The Commodification of Self*, 5 *The Hedgehog Review* 41, 44-49 (2003)。

〔46〕 实践中，主播经纪合同的违约金设置颇为复杂。以成都某有限公司与邓某合同纠纷案（四川省成都市成华区人民法院（2025）川0108民初75号民事判决书）为例，案涉违约金条款不仅将从未经同意的“私播”“延迟开播”到“泄露商业秘密”“擅自退出公会”等大量行为均纳入根本违约范畴，以最大限度地控制主播的职业行为，而且在违约金计算上采用固定数额、公司投入的倍数、预期利益、主播历史收益的倍数等多种计算标准，并约定取最高者。这种“取高”条款旨在确保违约发生后经纪公司能获得最大程度的赔偿，但往往导致违约金数额极高。

〔47〕 有观点认为演艺经纪合同属于融合委托、居间等典型合同构成要素的混合合同，原则上不能适用委托合同中的任意解除权规则（参见刘承魁：《论演艺经纪合同的解除》，《清华法学》2019年第4期，第136页以下）。但若合同中明确约定了经纪公司一方享有随时解除合同的权利，也有判决对此予以认可（参见郑州某国际贸易有限公司与王某合同纠纷案，河南省中牟县人民法院（2022）豫0122民初7363号民事判决书）。

〔48〕 即约定合作期内主播仅享有相关账号的使用权，一旦合同解除或终止，账号和相关的客户资料均归经纪机构所有。有法院认为此类条款属于“排除对方主要权利”的格式条款，应认定无效（参见沈阳某汽车信息咨询有限公司与王某合同纠纷案，辽宁省沈阳市中级人民法院（2021）辽01民终2578号民事判决书）；也有法院认为应尊重契约自治，认定此类条款有效（参见大连某传媒有限公司与王某合同纠纷案，辽宁省大连市金州区人民法院（2025）辽0213民初1405号民事判决书）。

〔49〕 实践中，资方为维护主播、艺人之特定人设，可能借助“道德条款”约束、限制其不当言行，对此自然无可厚非。此类条款有时也会采用较为宽泛的表述，如要求主播“保持健康的个人形象”（参见某文化传媒有限公司与程某合同纠纷案，浙江省宁波市江北区人民法院（2023）浙0205民初1292号民事判决书）。但若通过此类条款要求主播、艺人维持某种单一、固定的“人设”，不得有任何与资方设定不符的创作或表达，则可能构成对后者人格自由发展的不当限制。

程度进行分配。^[50] 比如,在对账号归属的判定中,如果账号的吸引力、内容风格与主播、艺人的个人特质高度融合、不可分割,则其人身属性显著增强,法律应倾向于保护主播、艺人对账号的控制权,以维系其身份发展的连续性。此时,资方的投入应通过收益分享机制而非获取账号控制权来实现回报。反之,若账号价值主要依赖于资方的系统性投入与运营,则应倾向于认可资方对账号的控制权。^[51] 法院在审查高额违约金条款时,同样需要综合考量资方的实际投入、合理预期利益损失、主播或艺人的过错程度,尤其应重视主播、艺人个人影响力在价值创造中的实际权重,以防范资方通过格式条款架空主播的身份权益。^[52]

需要补充的是,在消费者保护面向上,现行法的规制重心主要放在防范社会身份商业化利用过程中的虚假宣传与误导行为。例如,规范主播行为,对于为博取流量而进行的虚假身份叙事、夸大宣传等行为,设定了相应的责任规则。^[53] 然而,从社会身份建构的角度审视,同样不容忽视的还有消费者人格权益的“隐性”商业化利用问题。消费者在点击、点赞、分享等互动中产生的偏好数据,常在其不自知的情况下被平台收集、分析并形成用户画像,用于个性化推荐甚至更广泛的商业化利用,构成对其注意力与身份倾向的“二次商品化”。^[54] 对此,有必要要求平台建立合理的算法透明度机制,避免“将个人推向被操纵的客体地位”。^[55] 个人信息保护法第 24 条从自动化决策角度对用户画像行为进行了一定程度的规制,但其规制效能仍存在明显

[50] 与传统影视演员不同,网络主播的社会身份建构往往具有更强的动态交互性与平台依附性。影视演员的表演价值多凝结于最终成品中,其与角色的绑定在作品完成后相对固定;而主播的“前台表演”与其自我身份特质在持续直播互动中深度融合,其社会身份的价值与特定账号及粉丝社群紧密关联,有时难以像影视角色那样脱离具体平台和互动生态而独立存在。这种实时、高互动性的身份建构模式,使其法律关系的界定更需关注过程和贡献比例。

[51] 司法实践中,已有案例反映出类似规范思路。若账号的经济价值高度依附于主播的个人特质、劳动与粉丝关系,则其具有强人身属性,运营方难以依据合同当然取得控制权(参见青岛某创意有限公司与马某合同纠纷案,山东省青岛市城阳区人民法院(2022)鲁0214民初2361号民事判决书)。反之,若账号价值主要源于公司的资本投入、流量推广与商业运营,而非个人IP的直接影响,则账号可作为公司财产予以确认(参见江苏某文化传媒有限公司与葛某合同纠纷案,江苏省宿迁市中级人民法院(2024)苏13民终1419号民事判决书)。

[52] 在上海某文化传播有限公司与翟某演出合同纠纷案(上海市徐汇区人民法院(2021)沪0104民初13436号民事判决书)中,法院明确区分了虚拟角色商业价值的构成来源,指出账号估值并非艺人单方贡献的产物,而是其个人特质与公司成熟的商业运作、资源投入、内容制作等多重因素共同作用的结果。鉴于公司可通过专业运作维持账号价值,法院未支持以其商业估值全额认定损失的主张,而是综合考量公司在艺人出道、规划、流量及制作等方面的实际投入并结合账号潜在价值,对违约金进行了酌定。

[53] 如国家互联网信息办公室等七部门发布的《关于加强网络直播规范管理工作的指导意见》(国信办发文〔2021〕3号)、国家互联网信息办公室、国家税务总局、国家市场监督管理总局发布的《关于进一步规范网络直播营利行为促进行业健康发展的意见》(税总所得发〔2022〕25号)和国家广播电视总局、文化和旅游部发布的《网络主播行为规范》(广电发〔2022〕36号)等。

[54] 有学者指出,平台若纯粹以营利逻辑为主导,则可能将数字身份异化为需持续经营的“产品”。参见李中涵、陈继红:《数字化时代下人的数字身份的异化与扬弃》,《中南大学学报(社会科学版)》2025年第2期,第205页。

[55] 参见许可:《算法规制体系的中国建构与理论反思》,《法律科学》2022年第1期,第132页。

局限性。一方面，消费者的数字行为痕迹往往难以被纳入强调可识别性的传统个人信息范畴；^{〔56〕}另一方面，现行个人信息保护制度的规制重点仍侧重于个体数据而非群体身份建构过程中的系统性影响，难以有效应对平台通过塑造大规模用户集体行为与身份认同进行商业化利用的风险。因此，针对数字画像是否需要专门规范，有进一步探讨的必要。^{〔57〕}

（三）虚拟身份层的规范检视

在身份分层理论下，虚拟身份是指能够脱离人的物理实体、以数字化方式呈现并参与社会交往的身份形态。^{〔58〕}它与本真身份及社会身份的根本区别在于其“可分离性”与“代码建构性”。^{〔59〕}具体而言，虚拟身份并非物理存在与人格的直接延伸，而是由算法与数据驱动，能够在数字空间中相对独立地生成内容并进行交互的数字存在。^{〔60〕}这种特性既拓展了身份建构的边界，赋予个体前所未有的表达自由，也使其对数字自我的控制变得更为间接且脆弱，从而构成了法律规制的逻辑起点。从身份自主性的角度，^{〔61〕}有必要对两种虚拟身份进行区分：一是经主体授权、作为其意志延伸的“化身”（类似“孙悟空的分身”）；二是未经授权、意图混淆与替代的“数字孪生”（类似“六耳猕猴”）。^{〔62〕}前者依然属于主体自主性在虚拟空间中的拓展，后者则构成对身份自主性的直接侵害。

在人格权商业化利用背景下，对经主体授权的虚拟“化身”进行法律规制，其核心在于如何在技术赋能与商业运营的现实框架下，确保主体在授权后仍能维持对其虚拟身份的一定程度的有效控制。相较于传统人格要素如姓名、肖像的许可使用，虚

〔56〕 参见商希雪：《数字行为痕迹的法律定位与权益保障研究——全面应对 Deep Seek 等 AI 平台的个人信息保护挑战》，《暨南学报（哲学社会科学版）》2025 年第 2 期，第 76 页以下。

〔57〕 有学者认为，基于数据画像技术可能产生的社会风险，应采取特殊的个人信息保护机制，根据数据画像生成的不同阶段，对个人信息处理者设置具有区分度的义务要求，从而实现动态、精准的风险控制。参见丁晓东：《用户画像、个性化推荐与个人信息保护》，《环球法律评论》2019 年第 5 期，第 82 页以下。

〔58〕 有学者将基于真人形象创建的虚拟数字人分为两类：一是仅模仿人类外形的“数字人物形象”，二是精准复现特定真实个体特征的“数字仿象”（参见李昊、徐耀铭：《AI 技术背景下涉“虚拟数字人”的民事权利认定》，《法治研究》2025 年第 4 期，第 18 页以下）。本文所述“虚拟身份”，是指与物理世界的特定自然人存在映射关系的数字存在（不包括前述“数字人物形象”），关注在人格权保护维度下，个体脱离物理实体后在虚拟空间中的身份建构机制。

〔59〕 虚拟身份与社会身份的区分需结合技术介入程度来判断。例如，对公众人物言行进行戏谑性二次创作的视频，虽经数字化处理，但仍可能属于对其社会身份的表述与评论；而通过深度合成技术生成其语音或行为，则具有“代码建构性”特征，构成对人格要素在虚拟身份层的重构与利用。

〔60〕 在表现形式上，虚拟身份不限于人形形象，也可体现为生成式文本（如模仿特定个体的叙事风格）、合成语音包等。其映射的对象既包括生者，也可延及逝者。

〔61〕 基于对消费者和公众的信赖保护，无论是否经过主体授权，虚拟身份都存在“真实性”方面的规范要求。《网络音视频信息服务管理规定》第 11 条确立了对非真实音视频信息的标识义务；2025 年实施的《人工智能生成合成内容标识办法》第 4、5 条中进一步构建了显性标识与隐性标识相结合的双重标识体系，为虚拟身份的可信流通奠定了规范基础。

〔62〕 “数字孪生”是一种集成多物理、多尺度、多学科属性，具有实时同步、忠实映射、高保真度特性，能够实现物理世界与信息世界交互与融合的技术手段。参见陶飞等：《数字孪生及其应用探索》，《计算机集成制造系统》2018 年第 1 期，第 1 页以下。它本身是一个较为中性的概念，而在本文中特指他人通过采集与分析个人数据，在数字空间中建构出与被采集信息者人格特征高度相似的虚拟映射体。

拟“化身”所涉权利义务内容尚未在法律层面得到清晰界定，^{〔63〕}其具体范围往往因应用场景与商业模式的差异而呈现动态变化。鉴此，法律规制可从以下维度协同展开：其一，借助细致、前瞻的合同安排落实意思自治。授权协议应超越传统人格要素许可的静态框架，就“化身”的行为边界、价值导向、应用场景作出具体约定，并赋予主体在运营过程中的审查权、持续监督权以及对“人设”重大变更的否决权。此外，合同中也可约定因授权主体线下行为（如“人设崩塌”）导致虚拟身份价值减损时的违约责任，以平衡运营方的合理商业期待利益。其二，对运营方施加必要的法定义务与行为规范。^{〔64〕}比如，要求运营方在合理范围内向授权主体解释影响“化身”行为与表达的关键算法逻辑与决策依据，并要求其在算法设计中内置必要的干预接口，使授权主体在技术上具备对“化身”显著偏离其意志或价值观的行为进行及时纠正的能力。^{〔65〕}其三，在责任分配上，应综合考察授权主体、运营方及技术提供者各方对“化身”生成内容的影响程度、技术控制的可能性及事后补救的可行性等因素来明确各方责任。^{〔66〕}

对未经授权恶意创设的“数字孪生”进行法律规制，规范核心显然更在于遏制身份盗用并修复其对人格自主性的侵害。对此，也可从三方面加以思考：第一，在侵权与否的认定上，可结合虚拟身份的特殊性，以“映射强度”为关键判断标准（即社会公众能否将虚拟身份稳定、明确地关联到特定主体），在人格权保护与表达自由之间进行精细平衡。例如，对公众人物形象的二次创作若已转化为艺术评论，可能落入合理使用范畴；而利用深度伪造技术生成足以误导公众的视听内容，则显然超出了合理使用范畴。至于是否构成侵权，还需作场景化判断，即综合考量其使用目的、对原权利人市场的替代效应以及是否损及人格尊严等因素。第二，在受侵害法益的认定上，此类行为通常构成复合权益侵害。若擅自使用他人肖像、姓名、声音等可识别性

〔63〕 在虚拟数字人产业权益归属存在法律模糊地带的情况下，开发公司常通过劳动合同中的弹性条款预设权益安排。例如，在某科技公司与真人模特的合同中，不仅约定模特在受雇期间的职务成果归属于公司，还进一步约定，即使根据法律某些权利必须归属于雇员且不允许合同另行约定，雇员也应在最大程度上将相关权益转让给公司。这类条款反映了当前法律滞后于技术发展时，市场主体为明确权益边界所采取的过渡性安排。参见某（上海）信息科技有限公司与杭州某光纤网络有限公司侵害著作权、表演者权及不正当竞争纠纷案，浙江省杭州市中级人民法院（2023）浙01民终4722号民事判决书。

〔64〕 有学者敏锐地指出，目前法律规制范式存在“权利过剩”的倾向，应转向以“义务本位”为核心的责任治理，通过明确运营方、平台等强势方的法定义务和行为规范，将义务要求嵌入算法架构，才能实质性地重构数字法的规范体系，应对数字权利实现难的挑战。参见孙笑侠：《论数字权利的关系变异》，《法律科学》2025年第6期，第53页以下。

〔65〕 个人信息保护法第24条第3款赋予了个人对自动化决策的要求说明与拒绝权，但该权利以“重大影响”为启动门槛，且侧重事后救济。而虚拟身份的运行动态、持续，其风险往往是累积性而非单次“重大”的，导致该条款难以实现对其有效的过程控制。针对此局限，已有学者主张拓展条文内涵，赋予个人在自动化决策全流程中“分阶段、分场景、分情况”的主动参与权利，从而形成与技术动态性相匹配的持续控制机制。参程啸、王苑：《个人信息保护法教程》，中国人民大学出版社2023年版，第112页以下。

〔66〕 有学者提出，应依据人类介入与指令干预的强弱，将智能体划分为参考型、协作型及独立型，并据此构建差异化的效力归属与责任承担规则。参见郭少飞：《代理视域下人工智能体缔约研究》，《上海政法学院学报》2024年第6期，第70页。

要素，则直接构成对民法典规定的具体人格权的侵害；同时，基于对个人信息的使用，该行为也可能构成对个人信息权益的侵害。^{〔67〕}若相关行为无法为具体人格权完全涵盖，尤其是涉及对人格自由、人格尊严的深层侵害时，则可诉诸民法典第 990 条规定的一般人格权予以兜底保护。第三，在救济措施层面，应兼顾人格利益与财产利益的双重填补。权利人可主张停止侵害、消除影响、赔礼道歉等，对持续性、扩散性的侵害行为，可依法申请人格权禁令。但在财产损害赔偿的计算上，笔者认为还须格外审慎。依据民法典第 1182 条，侵权人所获利益可作为确定赔偿数额的参考，但此处应认识到虚拟身份的价值往往融合了人格要素、技术投入、平台运营与市场机遇等多重因素。因此，在计算赔偿额时，在侵权获利中可能需要剥离侵权人自身的资本、技术及其他正当经营投入所对应的价值部分，盖损害赔偿原则上应定位于对权利人许可机会损失的合理填补，而非过度惩罚。

最后需要补充的是，虚拟身份能够脱离物理肉身而存续的特性，极大地拓展了人类身份建构的边界，为个体超越生物学意义上的生命终点，在数字空间实现身份建构的延续提供了技术可能，同时也带来了巨大的伦理和法律风险。^{〔68〕}“数字复活”技术的商业化利用，大致可以分为两种情形：一是为缅怀死者而提供虚拟“化身”的商业服务（可能基于死者生前安排、近亲属甚至好友的委托），二是超出缅怀目的的纯商业开发行为。无论前者还是后者，个人信息保护法第 49 条都是重要的规范依据。其除了赋予尊重死者意愿以绝对优先地位外，还通过“自身的合法、正当利益”对近亲属行使死者个人信息相关权利提供了颇具弹性的评价标准。比如，针对使用个人信息创设死者虚拟身份的行为，可以结合场景作更细致具体的判断，为缅怀目的的使用自然比纯商业利用目的的使用更容易符合“自身的合法、正当利益”的评价。^{〔69〕}又比如，若为抵御建立在死者个人信息基础上的不当商业开发行为，单个近亲属即有权“合法、正当”地行使相关救济性权利；^{〔70〕}相反，若拟积极利用死者个人信息进

〔67〕 即使处理的是已公开个人信息，若该处理行为对个人权益有重大影响，依据个人信息保护法第 27 条，仍应取得个人同意。

〔68〕 参见李沐芝：《人工智能“复活”逝者：伦理风险及其法治进路》，《昆明理工大学学报（社会科学版）》2025 年第 1 期，第 58 页；刘永谋、白英慧：《生命哲学视域下的数字永生问题》，《浙江社会科学》2025 年第 2 期，第 84 页；张富利：《从死后即焚到数字永生？——关于个人数字遗产的探讨》，《山东大学学报（哲学社会科学版）》2024 年第 2 期，第 166 页。

〔69〕 学界对是否允许死者个人信息的积极商业利用尚存较大争议。否定说认为“数字复活”技术商业化利用空间极窄，仅在死者生前有明确安排时方有空间。参见王琦：《数字复活的法律规制》，《法治研究》2025 年第 4 期，第 46 页。相反观点认为，死者近亲属对死者个人信息享有广泛的权利，在不违背死者意愿的前提下，可以积极发挥死者个人信息的经济效用，但在涉及公开利用时，由于可能会对近亲属造成二次伤害，须征得全部近亲属的同意。参见张凌寒：《直面人工智能“复活”技术应用的伦理挑战》，《人民论坛》2024 年第 11 期，第 56 页以下。

〔70〕 《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2021〕15 号）第 15 条明确，自然人死亡后，信息处理者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定处理人脸信息，死者的近亲属可依据民法典第 994 条请求信息处理者承担民事责任。若延续该司法解释的审判思路处理死者虚拟身份层面的侵权责任承担问题，进而严格适用民法典第 994 条，近亲属在主张死者权益保护时还存在顺位问题。

行商业开发,为最大限度地维护死者(可能的)意愿和避免对死者造成不可逆的身份建构风险,经多数乃至全部近亲属同意则更为妥当。^[71]还须特别说明的是,是否同意利用死者个人信息创设虚拟身份,与是否允许继受由此产生的财产利益,属于两个不同层面的问题,前者涉及个人信息保护相关规则,后者则更宜纳入继承法的调整范围。

(四) 三层身份之间的综合检视

在对各身份层完成规范检视后,有必要对身份分层理论作进一步的综合检视。

首先需要指出的是,在具体实践中,三个身份层之间的边界并非始终清晰可辨,各身份层也难以简单地与传统人格要素分类一一对应。例如,个人声音既关涉独特的生物特征(本真身份),也可作为重要的社会交往标识(社会身份),还可能成为数字合成与操纵的对象(虚拟身份)。更为关键的是,各身份层之间存在明显的“涟漪效应”:对虚拟身份的深度伪造可能侵蚀社会信誉,而社会身份的标签化亦可能通过心理暗示持续渗透,最终波及个体的本真认知。

虽然如此,对身份进行分层并非只是徒增困扰的“多此一举”。通过前文对诸多问题的研讨可知,提出这一理论的旨趣并非以繁复的概念构造平添法律适用之困,而是力图借助结构化的分析框架,推动研究视角从追问“何种人格要素或人格标识被商业化”,转向动态地考察“人格要素在哪个身份层面、以何种方式被商业化”,从而提供更为精准的评价工具,以回应数字时代人格权商业化利用面临的种种难题。

除在法律适用层面的具体应用外,身份分层理论亦具有方法论层面的指引作用,有助于超越具体法律条款,对一些涉及各层面的基础性、综合性命题进行系统性反思。在权利基础层面,面对人格要素在数字语境中的种种解构与重组,现行法上关于具体人格权与一般人格权的二分框架略显局促。是否有必要借鉴意大利司法经验确立“个人身份权”,以保护个人在身份建构中形成的“社会镜像”不被他人无端歪曲,在此基础上进一步思考数字语境下个人身份权的延展适用问题,^[72]抑或认为数字技术构成某种颠覆性的变革,直接在传统人格权之外创设某种仅适用于数字化语境的“数字形象权”,^[73]依然有探讨的空间。^[74]在行为规制机制层面,需重新审视“同

[71] Cfr. Mauro Tescaro, *La tutela postmortale della personalità morale e specialmente dell'identità personale*, in AA.VV., *Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Vol. I: I diritti fondamentali fra concetti e tutele*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, p.845, nota 94.

[72] 关于意大利个人身份权的具体介绍,参见前引[2],陆青文,第9页以下。

[73] 参见徐伟:《论数字形象权——基于数字人作为新型人格权客体的证成》,《法治研究》2025年第4期,第45页。

[74] 在我国现行法框架下,确立个人身份权或数字形象权都面临一定的困难。一方面,个人身份权缺乏明确的规范基础,也难以进行精准的体系定位。相较于更为抽象、原则的一般人格权,个人身份权更宜被界定为一项具体人格权,但相比指向特定人格要素的姓名权、肖像权等,个人身份权的保护范围又覆盖多种人格特质,呈现出“框架性权利”的特征。另一方面,数字形象权以“数字人”作为新型人格权客体,但“数字人”本身概念模糊,其法律边界、属性认定均未明晰。更为关键的是,数字形象与人格尊严的内在关联还有待充分论证,为何将其归入人格权而非财产权范畴,还须理论上的进一步澄清。

意”与“合同”这两种核心法律工具在身份建构中的功能定位与互动关系。二者虽均为意思自治的实现机制，但性质与侧重有所不同：“同意”更具防御性，表现为对他人安排的消极确认或拒绝；“合同”则更为积极主动，可通过事前协商建立持续合作的框架，实现利益的流转与安排。在身份被持续、动态商业利用的语境下，二者功能不可偏废：一方面，须强化“同意”的真实性、具体性与自主性，以对抗实践中常见的“捆绑同意”“强制同意”；另一方面，也应鼓励通过更具前瞻性、更精细化的合同设计，将对身份的控制与利用规则嵌入商业合作的全过程，从而实现从静态授权到动态治理的范式升级。在治理结构层面，身份建构的各个层面显然都涉及公私法的协同问题。若公法管制无法勾勒清晰的外部边界，私法层面的权利配置与意思自治便可能迷失方向，甚至异化为对人格尊严的侵蚀；反之，若脱离私法所建构的、贯通线上线下场景的权利义务配置，公权力的介入亦将丧失必要的制度支点与规范弹性，难以形成有效的治理合力。与此同时，身份分层理论引导我们进一步关注不同身份层在公私法协同治理上的重心差异：在本真身份层，公法需侧重于更为严格、精细的法律、伦理审查与技术准入限制等，私法则应在尊重主体有限自决的同时设定不得违背人格尊严的底线；在社会身份层，公法应着重维护健康有序的市场秩序并保障公众信赖，私法则通过合同、侵权等制度实现商业利用中的公平与意思自治；在虚拟身份层，公法须着重应对由身份代码化、数据化带来的身份冒用、盗用、滥用等系统性风险，私法则需针对虚拟身份的可分离性与算法建构性，探索与之相适应的权利形态及自治规则。

结 语

正如相对论与牛顿力学的关系所示，新研究范式的意义往往不在于否定既有理论，而在于以更开阔的视野将其包容在内并延展认知的边界。本文尝试提出的身份分层理论，也并非意图颠覆传统人格权规范，而是希冀在尊重现有学理的基础上，探索一种可能更具包容性与适应性的分析视角，以应对数字时代人格权商业化利用带来的多层次挑战。当然，这一探索仍处于初步阶段，理论完善性与实践有效性尚待更多检验与批评。

不可否认，法学具有相对保守的一面。这导致在数字法学的研究中，提出一种新的理论、一种新的思考范式，难免让受众产生抵触心理，不仅会遇到负面评价，更可能对既有学理和实务滋生不必要的困扰。但另一方面又不得不承认，数字时代的到来给传统人际关系的调整带来了巨大冲击。主体与客体、人身与财产、归属与利用等传统法上作为基石的理念，似乎都在不同程度上受到了挑战。在纷繁复杂的新现象、新问题面前，法律人的核心使命就是借助对复杂事物的敏锐洞察力，找到化解难题的钥匙。要获得这种洞察力，自然依赖于学者自身的体悟，但增加与其他学科的对话，吸收其他学科的观察并将其融入规范分析之中，或许是更需要努力的方向。以法学之外的见识来增强对法学命题的洞察力进而反观现有制度，或许是交叉学科深度融合的真

正途径。本文对身份分层理论的提炼,正是在这种思考下的初步尝试。

身份分层理论是否足以解决数字时代人格权商业化利用的种种难题,笔者并未给出一个完整而成熟的答案。然而,这并不妨碍探讨确立身份之不同维度与层次的必要性。如果人格权的发展始终源于对人格尊严应如何获得更好保护的持续审视,并在种种实践需求的推动下,从确立各项具体人格权逐步上升为一般理论,甚至进一步抽象出更具涵摄性的权利形态,那么围绕身份建构来重新思考人格权的保护与利用机制,实则与费孝通先生提出的“差序格局”形成某种呼应。^{〔75〕}或许,这正是事物本然的结构,也是人格权规范体系所应呈现的底层逻辑。

Abstract: The advancement of digital technology is profoundly reshaping the paradigms of presentation, dissemination, and utilization of personality traits. This has rendered the commercial exploitation of personality rights increasingly integrated and fluid, posing a systemic challenge to the traditional theoretical paradigm centered on a “list of objects of rights”. The essence of such commercial exploitation lies not in the simple licensing of some elements of personality, but in the symbolic reproduction of “personal identity”, a comprehensive construct based on the subject’s personality traits. Drawing upon the theory of identity stratification, identity presentation in the digital context can be parsed into three levels, i.e., authentic identity, serving as the foundation of human dignity and the autonomous core, social identity, constructed through role performance and public image in social interactions, and virtual identity, a digital existence driven by algorithms and data that can be detached from physical entities. These three dimensions constitute a “concentric differential pattern” extending from the personality core to the periphery, characterized by continuous permeation, interaction, and mutual constraint. Rather than proposing a complex conceptual taxonomy, the theory of identity stratification aims to provide a substantive and structured analytical framework. Normative examination and integrated analysis of these identity layers demonstrate that this framework offers more specific guidance for assessing infringements on personality interests and defining the boundaries of commercial use, thereby achieving a dynamic balance between the protection of human dignity and digital innovation.

Key Words: personality rights, identity construction, commercial exploitation, personal information protection, virtual identity

〔75〕 参见费孝通:《乡土中国·生育制度·乡土重建》,商务印书馆 2011 年版,第 25 页以下。